

学生Aと学生Bは、次の【事例】について、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑦の()内に、後記aからnまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合、()内に入るものの組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、過去数回、飲酒酩酊の上、正常な運転ができない状態で自動車を運転し、物損事故を起こして運転免許取消処分を受けていたが、運転免許を再取得しないまま、自動車の運転を続けていた。

ある日、甲は、自動車を運転して居酒屋に行き、同居酒屋で飲酒し始めたが、仮に酩酊して正常な運転ができない状態になっても、自動車を運転して帰宅するつもりであった。

甲は、同居酒屋で日本酒1升を飲み、酩酊して是非善悪の識別能力及びその識別に従って行動を制御する能力を失った状態で、帰宅するために自動車の運転を開始した。しかし、甲は、飲酒酩酊により正常な運転ができなかったため、自車を歩道上に乗り上げさせて歩行中の乙を跳ね飛ばし、乙を死亡させた。

【会話】

学生A. この事例は、構成要件としては、(①) 罪に当てはまりそうだけど、甲は、運転開始時、是非善悪の識別能力及びその識別に従って行動を制御する能力を失った状態だね。

学生B. そうすると、運転開始時に甲は(②) がなかったことになるから、甲は不可罰になるのだろうか。

学生A. 甲が(②) に影響が出ない程度に飲酒して、正常な運転が困難な状態で自動車を運転していたら(①) 罪が成立するのに、この事例が不可罰になるなんて納得できないな。

学生B. こういう場合に、甲の可罰性を根拠付ける理論として、(③) があったね。

学生A. 確か「直接結果を惹起した行為の際には(②) がなくても、その原因となった行為の際に完全な(②) があれば、完全な責任が問われる。」という理論だったよね。

学生B. この理論の根拠は何だろう。

学生A. (④) を維持しつつ、構成要件該当事実を原因行為まで遡及させる立場と、(④) の例外を認め、責任だけを原因行為時に遡及させる立場があるよね。

学生B. (②) を欠いた自分を道具として利用すると捉え、(⑤) と同様に考える見解は、前者の立場に分類されるね。

学生A. だけど、甲が乙を自動車ではねた時点で甲自身が道具といえるか問題となる場合として、甲が(⑥) だった場合があるね。

学生B. 確かに、道具といえるか問題があるね。判例は、(⑥) の場合、(③) の理論を(⑦) よね。

【語句群】

- a. 業務上過失致死 b. 危険運転致死 c. 責任能力 d. 行為能力
e. 原因において違法な行為 f. 原因において自由な行為
g. 行為と責任の同時存在の原則 h. 罪刑法定主義 i. 共謀共同正犯
j. 間接正犯 k. 心神喪失 l. 心神耗弱 m. 適用している
n. 適用していない

1. ①a ②c ③e ④g ⑤j ⑥l ⑦m
2. ①a ②d ③f ④g ⑤i ⑥l ⑦n
3. ①b ②c ③f ④g ⑤j ⑥l ⑦m
4. ①b ②c ③f ④h ⑤i ⑥k ⑦n
5. ①b ②d ③e ④g ⑤j ⑥k ⑦m

() には順に、① = b、② = c、③ = f、④ = g、⑤ = j、⑥ = l、⑦ = m と入り、したがって、正解は肢 3 となる。

① = b

本事例では、甲は「酩酊して正常な運転ができない状態になっても、自動車を運転して帰宅するつもり」で飲酒し、「酩酊により正常な運転ができなかったため、自車を歩道上に乗り上げさせて歩行中の乙を跳ね飛ばし、死亡させ」ているので、「アルコール……の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2 条 1 号）「人を死亡させた」（同条柱書）という危険運転致死罪の構成要件に該当する。よって、①には b「危険運転致死」が入る。

* 危険運転致死傷罪は、旧刑法 211 条 2 項から自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2 条に移され、「通行禁止道路の進行」（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2 条 6 号）という新たな行為類型が加えられた。

② = c

甲は、運転開始時に「是非善悪の識別能力及びその識別に従って行動を制御する能力を失った状態」であったが、かかる状態は心神喪失として責任能力が欠如する場合である。よって、②には c「責任能力」が入る。

③ = f ④ = g ⑤ = j

責任能力は実行行為時に存在することが必要である（行為と責任の同時存在の原則）。そのため、構成要件の結果を直接惹起する実行行為の時点で心神喪失であれば、処罰し得ないことになる。しかし、自ら原因を設定して責任無能力の状態を招き、その状態において犯罪結果を実現させた場合に不可罰として放置するのは法感情に反し適当でない。このような行為の可罰性を根拠づけるため主張されたのが、原因において自由な行為の理論である。原因において自由な行為とは、ある違法行為が責任無能力又は限定責任能力の状態でなされた場合であっても、その責任無能力等の状態が行為者の責任能力ある状態における行為によって自ら招いたものであるときは、当該違法行為に対し、完全な責任を問うことができるとする法理である。よって、③には f「原因において自由な行為」が入る。また、原因において自由な行為の理解には、大別すると、(1) 行為と責任の同時存在の原則を維持しつつ、構成要件該当事実（特に実行行為）を原因行為時にまで遡及させる見解と、(2) 行為と責任の同時存在の原則の「例外」を認め、結果行為を実行行為と解しつつそれに対する責任を原因行為時にまで遡及して問う見解に分かれる。よって、④には g「行為と責任の同時存在の原則」が入る。そして、(1) の見解には、原因において自由な行為は自己の責任無能力状態を「道具」として利用した形態であるとする間接正犯類似説がある。よって、⑤には j「間接正犯」が入る。

⑥ = l ⑦ = m

間接正犯類似説に対しては、限定責任能力（心神耗弱）の状態において犯行を行った場合には、道具状態にあるとはいえないから原因において自由な行為を認めることができない、との批判がある。よって、⑥には l「心神耗弱」が入る。最決昭 43.2.27（百選 I 39 事件）は、「本件のように、酒酔い運転の行為が同時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、39 条 2 項を適用して刑の減軽をすべきではない」として、原因において自由な行為の理論を適用している。よって、⑦には m「適用している」が入る。